

1500511-04.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500511-04.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2097828/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 24195607 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2097828 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO MORENO

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 03 dias do mês de agosto de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Paulo Kishi e o Defensor, dr. Bruno André Silva Ortega. Apresentados o acusado RODRIGO MORENO, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes Pedro Carlos Girhã e Joel Vasconcelos de Lima.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do acusado com seu defensor, em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao acusado a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos os depoimentos das testemunhas (Pedro e Joel) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado o réu.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza,

RODRIGO MORENO foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 08 de abril de 2022, por volta de 17h52m, na rua Dom Manoel, altura do numeral 1061, bairro Jardim Ibirapuera, nesta cidade e comarca, trazia consigo 34 porções de maconha e 24 "pedras de crack", drogas destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os fatos imputados na exordial acusatória foram comprovados ao longo da instrução criminal, pelo que a ação é procedente.

A materialidade foi comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e Laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 98/100).

A autoria, da mesma forma, é indubitosa.

Segundo se apurou, guardas civis passavam pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando perceberam que o denunciado, que estava parado na via e empreendeu fuga ao avistar a aproximação da viatura.

Durante a evasão, o denunciado dispensou um objeto ao solo. Realizada abordagem, em poder do denunciado nada de ilícito foi encontrado. No entanto, verificou-se que o objeto que havia sido dispensado por ele continha 34 (trinta e quatro) porções de maconha e 24 (vinte e quatro) porções de "crack", além da quantia de R\$ 97,75 espécie.

Informalmente, o denunciado admitiu que estava no local para vender entorpecentes. Perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio.

Diante das circunstâncias apuradas, ou seja, pelo local da prisão, apreensão de porções individualizadas e dinheiro, evidencia-se que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas

A testemunha Pedro Carlos Girhã, guarda civil, narrou "estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos. O guarda afirma que, ao passar por um estabelecimento comercial sem nome em que comumente há venda de drogas nas imediações, avistou uma pessoa sozinha, parada na via. O guarda afirma que a pessoa em comento, a qual ora figura como indiciada, ao visualizar a aproximação da viatura, começou a correr em desabalada carreira. O guarda afirma que, diante da fundada suspeita, acompanhou o indiciado com a viatura. Segundo o guarda, o indiciado, durante a fuga, dispensou um objeto ao solo e foi detido na sequência, na mesma via. O guarda afirma que, em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado na posse do implicado. No entanto, seu parceiro de farda retornou ao local da dispensa do objeto e verificou tratar-se de um estojo de óculos, dentro do qual havia trinta e quatro porções de maconha e vinte e quatro porções de crack, bem como dinheiro em espécie. O guarda afirma que, de maneira informal, o indiciado confessou que estaria passando por necessidade financeira e estaria no local vendendo drogas." (fls. 04).

Em juízo ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial. Não conhecia o réu. Presenciou o momento em que ele dispensou a droga. Próximo ao local da abordagem há um bar. O réu foi visto na esquina há aproximadamente 50 m do bar. Ele foi abordado na sequência.

A testemunha Joel Vasconcelos de Lima, guarda civil, asseverou "estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos. O guarda afirma que, ao passar por um estabelecimento comercial sem nome em que comumente há venda de drogas nas imediações, uma pessoa começou a correr da viatura sem motivo algum, motivo pelo qual decidiu realizar acompanhamento. Segundo o guarda, a pessoa em comento, ora indiciado, durante a fuga, dispensou um objeto ao solo e foi detido na sequência, na mesma via. O guarda afirma que, em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado na posse do implicado. No entanto, retornou ao local da dispensa do objeto e verificou tratar-se de um estojo de óculos, dentro do qual havia trinta e

quatro porções de maconha e vinte e quatro porções de crack, bem como dinheiro em espécie. O guarda afirma que, de maneira informal, o indiciado confessou que estaria passando por necessidade financeira e estaria no local vendendo drogas" (fls. 85/86).

Em juízo ratificou o depoimento prestado na fase policial. Não conhecia o réu.

Perante a autoridade policial o réu permaneceu em silêncio (fls. 06/07).

Interrogado em juízo, o réu alegou que estava em frente ao bar bebendo com Guilherme, quando chegou uma viatura. Todos saíram correndo e correu também porque estava de condicional. Não dispensou nenhuma droga. A droga não lhe pertencia. Diante do todo apurado há provas suficientes que demonstram que o réu foi o autor do delito imputado na inicial.

A narrativa dos guardas foi firme e uníssona em confirmar que passavam pelo local, quando avistaram o réu, em local conhecido como "ponto de tráfico de drogas", e ao perceber a aproximação empreendeu fuga imediatamente. Diante da suspeita, iniciou-se breve perseguição. Durante a evasão, o réu dispensou algo ao solo. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em poder dele. No entanto, constatou-se que o objeto dispensado continha 34 porções de maconha e 24 porções de "crack", além da quantia de R\$ 97,75 em espécie. Instado, informalmente, ele confessou o crime.

Pertinente salientar, que não há nada que invalide os depoimentos dos guardas civis, devendo ser valorados como as demais provas constantes no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j .05/05/2016) – Grifo nosso. As circunstâncias apuradas e local da prisão indicam que a droga destinava-se à mercancia ilícita.

Ademais, não se pode olvidar que o réu é reincidente específico, o que confirma envolvimento com o crime em questão. Ainda, caso a droga não lhe pertencesse, não haveria justificativa para empreender fuga do local.

Destarte, imperiosa a condenação do réu pelo delito em questão.

Passo a analisar a dosimetria da pena.

Na primeira-fase a pena pode ser fixada acima do mínimo legal, pois o réu ostenta maus antecedentes.

O réu é reincidente específico. Ausentes circunstâncias atenuantes e causa de aumento.

A reincidência específica impede o reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Tratando-se de delito assemelhado ao hediondo e tendo-se em conta a necessidade de se individualizar a pena para a adequada prevenção e reprovação, incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo o réu iniciar o desconto da pena no regime inicial fechado.

Destarte, requer seja julgada procedente a ação penal e o réu condenado nos exatos termos da inicial.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente garantia da ordem pública, deverá ser indeferido apelo em liberdade.

Dada a palavra ao nobre defensor do acusado, manifestando-se sua Excelência, conforme gravação que segue no Teams.

Em seguida pela MM.Juíza foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

RODRIGO MORENO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 08 de abril de 2022, por volta

de 17h52, na Rua Dom Manoel, altura do numeral 1061, bairro Jardim Ibirapuera, nesta cidade e comarca, trazia consigo 34 porções de maconha e 24 “pedras de crack”, drogas destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas civis passavam pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando perceberam que o réu, que estava parado na via, empreendeu fuga ao avistar a aproximação da viatura.

Durante a evasão, o réu dispensou um objeto ao solo. Realizada a abordagem, em poder do réu, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, verificou-se que o objeto que havia sido dispensado pelo réu continha 34 (trinta e quatro) porções de maconha e 24 (vinte e quatro) porções de “crack”, além da quantia de R\$ 97,75 em espécie. Informalmente, o réu admitiu que estava no local para vender entorpecentes. Perante a autoridade policial, ele permaneceu em silêncio.

Diante das circunstâncias apuradas, ou seja, pelo local da prisão, apreensão de porções individualizadas e dinheiro, evidencia-se que a droga apreendida se destinava à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

A denúncia foi oferecida (fls. 76), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 82/83). Notificado (fls. 91), o réu apresentou defesa prévia, na qual alegou que as questões de mérito serão alegadas posteriormente, na instrução probatória (fls. 92/93).

A denúncia foi recebida, designando-se a audiência (fls. 101/103). O réu foi citado (fls. 143/144).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, em memoriais e debates orais, as partes se manifestam.

É o relatório.

DECIDO.

I - Da Preliminar

Pleiteia a Defesa, o reconhecimento da nulidade do processo, em razão da prisão realizada por guardas municipais. Argumenta que houve diligência típica de atividade policial, não permitida aos guardas municipais.

Não há, contudo, qualquer nulidade na prisão em flagrante do réu.

Não se verifica qualquer abuso ou ilegalidade na diligência efetuada pelos guardas municipais que, em local conhecido por intenso ponto de venda de drogas, suspeitaram do réu que, ao visualizar a viatura correu em desabalada carreira e, depois, durante a fuga, dispensou objeto, sendo abordado, na sequência. Assim, a conduta do réu não deixava dúvidas a respeito da ação ilícita dele e, por isso, a atuação da Guarda Civil foi lícita.

Por fim, a Lei nº 13.022/14 conferiu expressamente à Guarda Municipal a atribuição de polícia ostensiva, nos termos do artigo 3º da referida legislação, que assim dispõe: “Artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força”.

De qualquer modo, nada obstante o disposto no artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, é certo que, à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal, não há uma proibição de que os guardas municipais prendam alguém em flagrante, haja vista que qualquer pessoa do povo também pode fazê-lo.

E, no caso concreto, ao contrário do postulado pela Defesa, o réu foi abordado logo após dispensar drogas, havendo flagrante, consoante prevê o artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de

Processo Penal - CPP.[...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.º 603.686/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021) Ante o exposto, não conheço o presente habeas corpus. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator. (STJ - HC: 676532 SP 2021/0199414-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 29/06/2021).

"O recurso comporta parcial provimento. No caso, quanto à prisão em flagrante realizada por guardas municipais, inexistente ofensa aos alegados dispositivos de lei federal, pois o entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte consolidada no sentido de que, "apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão" (HC n. 286.546/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015). Nesse sentido, confira-se ainda: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal" (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019) 5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 525.772/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019). Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para, na segunda fase da dosimetria, compensar integralmente a agravante de reincidência com a atenuante de confissão, fixando a pena definitiva do paciente em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 11 dias-multa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator (STJ - REsp: 1940142 SP 2021/0159530-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 28/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO FLAGRANCIAL ILEGAL. GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexistente ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 2. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 667413 SP 2021/0152075-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Nesse sentido também o Tribunal de Justiça de São Paulo:

PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. FALTA DE COMPETÊNCIA PARA O ATO. INEXISTÊNCIA. O Estatuto das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/14), regulamentou o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, estabelecendo que compete à Guarda Civil Metropolitana, entre outras atribuições, prevenir, inibir e coibir infrações penais, bem como encaminhar indivíduos em flagrante delito à autoridade policial (art. 5º, II, III e IV da referida Lei). Ademais, como qualquer do povo, esses servidores podem efetuar a prisão em flagrante do agente cuja conduta se amolde às hipóteses taxativas do artigo 302 do Código de Processo Penal. Guardas civis municipais que foram alertados por transeunte sobre a conduta do réu, dirigiram-se ao local, observaram a prática de atos típicos de traficância e efetuararam sua prisão em flagrante delito. Ausência de ilicitude da busca pessoal que culminou na apreensão das drogas e dinheiro e o início da persecução penal. Preliminar rejeitada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO

MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Guardas civis, após denúncia de traficância, avistaram o réu Yan em movimentação típica de tráfico com dois indivíduos e o surpreenderam na posse de duas porções de cocaína, vindo a localizar, no local de onde empreendera fuga, outras cinco porções da mesma droga, idênticas, e R\$ 20,00. Silente na fase extrajudicial, apelante negou em juízo o tráfico de drogas. Negativa e versão judiciais, além de fantasiosas e inverossímeis, sucumbiram à prova produzida pela Acusação. Condenação mantida. PENAS. Base fixada no mínimo legal. Pleito ministerial atendido para reconhecer-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, haja vista a prática do crime durante o estado de calamidade pública da pandemia de COVID-19, mormente no caso dos autos, em que se apura crime que visa a resguardar a saúde pública. Mantido o reconhecimento da reincidência. Negada a aplicação do redutor, por vedação legal expressa. Pena majorada. REGIME PRISIONAL. Regime inicial fechado mantido, ante a quantidade de pena aplicada e a reincidência específica, além da gravidade concreta do delito praticado. Regime inicial fechado mantido. BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ante a quantidade de pena corporal (superior a quatro anos) e a reincidência específica do réu. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo defensivo desprovido, com provimento ao recurso ministerial para, reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, redimensionar suas penas para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mínimos, com expedição de ofício de recomendação em seu desfavor. (TJ-SP - APR: 15015986320208260599 SP 1501598-63.2020.8.26.0599, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 29/06/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/06/2021 - grifei).

"Pondera-se, também, que em casos como o dos autos, por ser o tráfico de drogas um delito permanente, possível é a prisão flagrancial, a qualquer tempo e por qualquer um do povo, a teor do que dispõe o art. 301 do Código de Processo Penal. Destarte, não há impedimento legal para que membro da Guarda Civil Metropolitana efetue prisões em flagrante. Nesse sentido é a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EFETUADO POR GUARDA MUNICIPAL. VALIDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, é possível que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, o agente municipal proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. 2. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. Precedentes. [...] 8. Ordem denegada. (HC 583.610/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020). PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CONDUTA FLAGRADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. [...] III - O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). IV - Firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes." (HC 357.725/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 12/5/2017). [...] Habeas corpus não conhecido. (HC 480.676/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. 1. Não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante e,

consequentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais, que estavam de ronda e foram informados da ocorrência da prática de tráfico de drogas na ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo (artigo 301 do Código de Processo Penal). 2. Recurso improvido. (RHC 20.714/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2007, DJe 04/08/2008). (TJ-SP - RVCR: 22502921020198260000 SP 2250292-10.2019.8.26.0000, Relator: João Morenghi, Data de Julgamento: 29/06/2021, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/06/2021- grifei).

Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - Preliminar de nulidade - Ilegalidade da prisão, efetuada por guardas civis - Réus em situação de flagrância, cuja prisão pode ser efetuada por qualquer pessoa - Artigo 301 do CPP - Preliminar rejeitada - Provas suficientes à condenação - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Apreensão de significativa quantidade de maconha em poder dos acusados - Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Penas-base fixadas em seus patamares mínimos - Circunstância atenuante da menoridade relativa reconhecida, mas sem reflexo nas penas - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas - Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida - Regime inicial fechado mantido - Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Rejeitada a preliminar, recursos de apelação desprovidos. Apelação da Justiça Pública - Associação para o tráfico de drogas - Fragilidade do conjunto probatório - Circunstâncias que parecem indicar mero concurso eventual de agentes e não associação de cunho permanente - Absolvição mantida - Colaboração com o tráfico de drogas na condição de informante - Hipótese de coautoria - Ré que decidiu atuar na venda de drogas em comparsaria com sua companheira, havendo a divisão de tarefas e de lucros entre ambas - Crime subsidiário aplicável somente à colaboração eventual e desvinculada do efetivo comércio de entorpecentes - Condenação pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 - Pena-base fixada em seu patamar mínimo - Circunstância atenuante da menoridade relativa reconhecida, mas sem reflexo na pena - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas - Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida - Regime inicial fechado - Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Recurso de apelação parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15029258520198260079 SP 1502925-85.2019.8.26.0079, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 25/06/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/06/2021)

II - Do mérito

No mérito, a ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, no laudo de constatação de fls. 15/16, nas fotografias de fls. 30/32, bem como no exame químico-toxicológico de fls. 99/100, segundo o qual foi detectada a presença das substâncias Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, nos materiais apreendidos.

2) Da autoria

A autoria do réu é certa e deve ser imputada ao réu.

Na fase investigativa, o réu permaneceu em silêncio (fls. 06).

Em Juízo, o réu disse que estava na frente do bar, na calçada, bebendo cerveja, com seu amigo Guilherme, quando viu a viatura chegando. Além deles, havia outras pessoas na frente do bar, umas seis pessoas. Algumas pessoas saíram correndo e outras andando. Também correu, porque estava devendo condicional. Somente ele foi abordado. Consigo, nada havia. Não dispensou o estojo. A droga não era sua. Não sabe o motivo da acusação. Usa maconha e cocaína e não conseguia ficar sem consumi-

las. Já tinha sido abordado pelo guarda civil Pedro, mas não foi preso. Ele o viu parado na frente de casa e o abordou. Nada tem contra os guardas civis. O guarda civil Pedro trabalha na região onde mora. Nunca foi ameaçado pelo guarda Pedro. A autoria foi comprovada pelos demais elementos de prova. Vejamos.

O guarda civil Pedro Carlos Girhão relatou que estavam em patrulhamento, em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o réu parado na esquina, sozinho. Ao perceber a viatura, o réu saiu correndo, mas foi abordado. Durante a fuga, o réu dispensou alguma coisa. Depois que o réu foi abordado, retornaram e encontraram o que ele tinha dispensado, ou seja, um estojo de óculos, no qual havia 34 porções de maconha, 24 porções de crack, R\$ 97.75. o réu confessou que estava praticando a venda de drogas e que o dinheiro era proveniente da venda já realizada. Não conhecia o réu. Viu o momento em que o réu dispensou o estojo. A rua possui casas e bar, frequentado por usuários e pessoas que vão comprar. Existe uma casa, onde se vendem coisas, como um bar. O réu não estava no bar, mas sim na esquina. O bar fica a 50 metros da esquina. Demoraram cerca de 01 ou 02 minutos, para deter o réu. Encontraram o estojo no chão, onde ele havia dispensado, a 05 metros de distância de onde o réu foi abordado. Não se recorda de ter abordado o réu anteriormente. Não se recordou a cor do estojo.

O também guarda civil Joel Vasconcelos de Lima asseverou que estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas intenso. Pela rua, avistaram, na esquina, o réu sozinho e parado e ele, ao perceber a viatura, saiu correndo. O réu estava próximo ao bar. Esse fato chamou a atenção, desembarcou da viatura e correu atrás dele. Antes de conseguir detê-lo, viu o réu dispensando alguma coisa que estava na sua mão. Conseguiu detê-lo e, em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. Debaixo do carro, encontraram o que ele tinha dispensado, ou seja, uma caixinha de óculos com entorpecente. Havia 34 porções de maconha e 24 porções de crack, além de dinheiro em notas diversas. Questionado, o réu confessou a prática do tráfico de drogas, porque estava com dificuldades financeiras. O réu confirmou que o dinheiro era proveniente do tráfico. Não conhecia o réu. Não se recorda se existiam outras pessoas no bar, porque já teve várias ocorrências no mesmo local. O bar é uma casa, onde a pessoa fechou o portão e fez o bar. Não se recorda se na rua havia mais pessoas. Só o réu correu e isso levantou suspeita. Não se recordou da cor do estojo.

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

O réu, em solo policial, nada alegou sobre os fatos a si imputados. Em Juízo, ele aduziu que estava bebendo com um amigo de nome Guilherme, na frente do bar, quando a viatura apareceu e várias pessoas que estavam na frente do bar correram, inclusive ele, que estava em condicional. Somente ele foi abordado em seguida, mas nada de ilícito estava sem eu poder. Negou que tivesse dispensado o estojo, onde estava a droga apreendida.

Os guardas civis narraram que ao passarem por local já conhecido como ponto de droga viram o réu parado na esquina, sozinho. Ao perceber a aproximação da viatura, o réu iniciou fuga, correndo. O guarda civil Joel desembarcou da viatura e correu atrás do réu. Durante a fuga, o réu dispensou alguma coisa debaixo de um veículo e, em seguida foi abordado. Em revista pessoal, com o réu, nada foi encontrado. O objeto por ele dispensado tratava-se de um estojo de óculos, dentro do qual havia 34 porções de maconha, 24 porções de crack e dinheiro em espécie. Questionado sobre os fatos, informalmente, o réu confessou aos guardas civis, que estava na prática do tráfico de drogas, em razão da sua necessidade financeira e o dinheiro era proveniente da venda espúria anterior.

Nesse contexto, existem duas versões sobre o mesmo fato: a do réu, que nega que tivesse dispensado a droga, e a dos guardas civis, no sentido de que a droga estava em estojo de óculos dispensado pelo réu, durante a tentativa de fuga.

Resta saber qual versão merece credibilidade.

Inicialmente, o réu estava em ponto de venda de drogas e empreendeu fuga, ao visualizar a aproximação da viatura policial, demonstrando que estava na prática de ilícito.

De outra banda, embora o réu tenha mencionado que estava na frente de um bar com

outras pessoas, os guardas civis descreveram que apenas ele estava na esquina, longe do bar e somente ele correu.

Por outro lado, o réu disse estar acompanhado do amigo Guilherme, no entanto, essa pessoa não foi arrolada como testemunha, para confirmar a situação fática que ele descreveu.

Nesse sentido, entendo que a versão dos guardas civis encontra amparo na prova, já que se não tivessem visto a dispensa da droga, os guardas civis não a teriam localizado, debaixo de um veículo.

Assim, a versão dos guardas civis encontra amparo no restante da prova e na apreensão de quantidade significativa de entorpecente.

Ainda que assim não fosse, devemos dar crédito ao depoimento uníssono e seguro dos milicianos que, como funcionários públicos, não estão impedidos de depor. Por outro lado, a palavra dos agentes policiais tem validade como prova, em especial, como no caso concreto, quando alicerçada no contexto probatório.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO MATERIAL PROSCRITO, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais militares representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação. Aliás, na falta de qualquer adminículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco para atuar no combate à narcotraficância, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar. (STF - HC: 215166 SC 0119154-54.2022.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/06/2022).

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Comprovado o envolvimento do réu com a droga, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprove a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11).

No caso dos autos, o réu alegou que não tinha qualquer droga em seu poder. A prova, contudo, confirma a destinação de consumo de terceiras pessoas.

O réu foi avistado parado e sozinho em local conhecido como ponto de venda de

drogas e, assim que avistou a viatura tentou fuga, saindo correndo. Essa conduta já demonstra que sua ação não era lícita.

A quantidade de droga apreendida (24 porções de crack e 34 porções de maconha) não é comumente encontrada com usuários de drogas, na via pública.

Com o réu, também havia dinheiro trocado (fls. 30 e 32), cuja origem lícita não foi comprovada.

Aos guardas civis, informalmente, o réu confessou que estava na prática da mercancia ilícita de drogas.

Assim, o local da abordagem, o comportamento do réu ao avistar a viatura, a quantidade e diversidade de droga e sua forma de embalagem, a existência de dinheiro e a confissão informal; tudo revela que a droga apreendida tinha como destinação o consumo de terceiras pessoas.

Ressalto que ainda que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito.

Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, de molde a evidenciar finalidade de venda" (TJRN, Ap. 00.001954-2, Câ. Crim., j. 1º.06.2001, rel. Juiz João Rebouças, V.U., RT 796/688).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão da dependência, inadmissível - Inteligência dos artigos 12 e 16 da Lei n.º 6.368/76" (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

A condenação, assim, é de rigor.

3) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

O réu possui maus antecedentes (Certidão de fls. 40 - Processo n. 0002214-81.2014.8.26.0451) de forma que sua pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal: reclusão de 05 anos e 10 meses e 583 dias-multa.

A reincidência (Certidão de fls. 41/42 - Processo n. 0014028-22.2016.8.26.0451) fará com que a pena sofra um aumento de 1/6: reclusão de 06 anos, 09 meses e 20 dias e 680 dias-multa.

O réu é reincidente, de forma que a causa de diminuição da pena do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não pode ser aplicada.

Não há mais atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

A pena privativa da liberdade cominada ao delito de tráfico de entorpecente há de ser cumprida em regime inicial fechado, uma vez que o delito de tráfico de entorpecentes continua sendo crime equiparado aos hediondos. Ademais, o réu apresenta antecedentes e reincidência pela prática do mesmo delito.

Pena final: reclusão de 06 anos, 09 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR RODRIGO MORENO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de reclusão de 06 anos, 09 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, diária mínima.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, em razão da quantidade da pena aplicada.

O réu está preso e assim deverá continuar caso deseje recorrer desta sentença. É que sua profissão (ajudante de pintor autônomo) não o prende ao distrito da culpa. Ademais, o réu possui outras duas condenações pela prática do mesmo delito, demonstrando que, em liberdade, pode manter-se na prática delitiva. Assim, a prisão cautelar é necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido (comprovante de pagamento a fls. 68) à União, já que provenientes do tráfico de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Com o trânsito em julgado desta sentença, remeta-se à Senad a relação de dinheiro decretado o perdimento em favor da União, indicando o local onde se encontram depositados, nos termos do artigo 63, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o réu junto à instituição penal que se encontra, servindo-se esta sentença, por cópia digitalizada, como ofício.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Tendo em vista que o réu manifestou desejo de recorrer da sentença, pela MM. Juíza foi dito: "recebo o recurso interposto pelo réu".

Pelo defensor foi dito que foi contratado pela família do réu apenas para defendê-lo até a sentença.

O réu já saiu intimado de que, no prazo de dez dias terá que constituir novo defensor e, em não o fazendo, deverá a serventia providenciar a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentar as razões de recurso.

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):

Ré(u):